

1501058-66.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HEBER GUALBERTO MENDONCA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos:

"O crime de tráfico privilegiado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

4ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501058-66.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501058-66.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO DE JESUS SANTOS

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEBER GUALBERTO MENDONCA

I - Do Relatório

LEONARDO DE JESUS SANTOS, qualificado às fls. 19, foi denunciado e processado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, em tese, no dia 23 de julho de 2021, por volta das 15h20, primeiro nas proximidades do Cemitério e depois na Rua Miguel Cueba Garcia, 57, cidade de Braúna, Comarca de Penápolis, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 10 porções de cocaína, além de ter em depósito, para a mesma finalidade, 172 porções da mesma droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta na denúncia que o réu estava encostado no muro do Cemitério, quando avistou os policiais militares. Ele ficou nervoso e levou a mão ao bolso, onde visivelmente havia um volume. Foi abordado.

Em revista pessoal, os policiais encontraram nesse bolso as dez porções de cocaína. Na ocasião, o indiciado admitiu o tráfico de drogas e informou aos policiais que o

restante do entorpecente estava em sua residência, na Rua Miguel Cueba Garcia, 57.

Os PMS foram ao local e, de fato, encontraram mais cento e setenta e duas porções da mesma droga, dentro do guarda-roupas, pelo que foi preso em flagrante delito.

Citado/notificado (fl. 146), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 193/197).

A denúncia foi recebida no dia 7.1.2022 (fls. 242/247).

Durante a instrução, ouviram-se 2 (duas) testemunhas comuns (fls. 293/294), sendo o réu interrogado ao final (fl. 292).

Em Memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, porém não se insurge contra a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º, da LAD, porém em seu patamar mínimo, dada a quantidade de drogas apreendida (fls. 289/291).

A Defesa do réu enfatizou ser caso de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da LAD em seu patamar máximo (fls. 289/291).

II - Da Fundamentação

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou plenamente comprovada pelo: i) boletim de ocorrência (fls. 4/9); iii) auto de exibição e apreensão (fls. 10/11); iii) laudo toxicológico (fls. 21/26).

A autoria também é certa, conforme se depreende da prova oral colhida.

A Testemunha/CPM Igor José de Oliveira estava em patrulhamento prestando apoio em Braúna e, próximo ao cemitério, viram o réu encostado com um volume em seu bolso. Ele tentou levar a mão no bolso e acharam estranho. Constataram ser 10 pinos de cocaína e aparelho celular. Ele disse ser pra venda e que tinha negociado e iria entregar, usando o celular para tanto. Ele informou o endereço, onde moravam o primo e a esposa, dizendo que tinha mais 172 microtubos de cocaína, meio tablete de maconha e uma balança de precisão. Foram ao local e encontraram os 172 microtubos, mas não encontraram a maconha e a balança, tendo a mulher dito que o primo Felipe levou embora, dizendo que sabia que ambos traficavam, mas que não era conivente com isso. Já havia denúncias dele envolvendo-o com o tráfico, mas nunca o abordaram até então. Desde a primeira abordagem, o réu colaborou com PM e prestou todas as informações.

A Testemunha/CPM Bruno Prado de Oliveira confirmou as informações de seu colega de corporação, acrescentando que o réu disse estar esperando o comprador da droga no cemitério e que negociava a venda pelo app do celular. Ele, de fato, confessou haver mais droga/microtubo de cocaína em sua casa, onde foram atendidos pela esposa, que franqueou a entrada deles no imóvel e reconheceu que o marido traficava com o primo dele, Felipe, que havia saído poucos momentos antes da chegada dos PMS na casa. Ele disse que haveria maconha e balança também, mas tais itens não foram encontrados - ou possivelmente retirado por Felipe. Desde a abordagem, houve colaboração do acusado o tempo todo. Ele indicou a droga no guarda-roupas.

Em seu interrogatório, LEONARDO DE JESUS SANTOS, disse que de fato o que os PMS disseram foi verdade. Não havia nada de maconha ou balança de precisão e não falou nada de maconha ou balança a eles. Ele mencionou os 172 pinos de pó dentro do guarda-roupa. Estava vendendo porque estava sem serviço - trabalhava na roça, mas nem sempre aparecia serviço, pois sua mulher estava grávida e paga pensão para outro filho. Felipe estava com ele no momento da abordagem e ambos foram abordados. Mas só ele foi com os PMS para sua casa. Felipe não. Estava vendendo há pouco mais de 1 semana. Sobre o crime organizado, disse que não faz parte disso. Quanto à

droga, pegou para vender e ficou de pagar depois. Felipe quem pegou essa droga em Birigui.

Pois bem.

O conjunto probatório é robusto e conclusivo.

Ambos PMs confirmaram a abordagem do réu e que, com ele, encontraram 10 pinos de cocaína, tendo o mesmo confessado que, em sua casa, havia mais 172 pinos da mesma droga, o que foi confirmado in loco.

Com efeito, o testemunho de policiais reveste-se de idoneidade e credibilidade suficientes a embasar, juntamente com os demais elementos de prova, o decreto condenatório. O simples fato de serem policiais não macula a prova oral de parcialidade, a não ser que haja prova em contrário nesse sentido, o que não ocorreu nos presentes autos.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial". (TJMG. Apelação Criminal nº 1.0349.08.020068-7/001. Relatora Des. MARIA CELESTE PORTO. 5ª Câmara Criminal. Julgado em 27/01/2009).

PROVA - Testemunha - Palavra de policiais quanto aos atos de diligência - Validade - Inexistência, nos autos, de qualquer evidência de má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público - Pedido revisional deferido em parte para reduzir a pena, fixado o regime inicial fechado (Revisão Criminal 99302019068600 - Monte Azul Paulista - Relator Antonio Sérgio Coelho de Oliveira - 16/04/2009 - Voto nº: 7929).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Credibilidade - A só condição de policial não o torna suspeito - Depoimento colhido sob compromisso de dizer a verdade, como de qualquer testemunha, que deve ser examinado dentro de todo o conjunto probatório - Seria estranho o Estado selecionar pessoas para integrarem o quadro da Polícia e depois suspeitar delas quando agem no cumprimento do dever, ainda mais se inexistente interesse dos policiais em prejudicar o acusado - Entendimento - Recursos parcialmente providos (Apelação Criminal 99305025506900 - São Miguel Arcanjo 11ª Câmara de Direito Criminal - Relator José Odorico de Oliveira Passos - 17/09/2008 - Voto nº 16.395).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Eficácia - Depoimentos de policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, harmônicos, coerentes e firmes que ratificam os fatos narrados na denúncia e nenhuma razão tinham para incriminar os acusados, sem motivo plausível ou causa justificável - Credibilidade - Recursos improvidos (Apelação Criminal 11391843000 - Barretos - 11ª Câmara do 6º Grupo as Seção Criminal - Relator Antônio Manssur 30/01/2008 - Voto nº 14.068).

Não bastasse isso, o próprio réu confessou que vendia os pinos pois estava desempregado, o que, de qualquer modo, não justifica sua conduta, tendo, como visto, colaborado com a ação policial.

Por sua vez, o acusado não conseguiu trazer aos autos qualquer evidência que faça pairar dúvida sobre as provas acima exploradas.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

Vejo que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis,

a teor da sua primariedade. Ademais, a análise das circunstâncias judiciais tem por finalidade adequar a quantidade da pena às particularidades que envolvem o fato e o agente, razão pela qual fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Sem agravantes. Quanto à confissão, considerando que já fixada a pena em seu patamar mínimo, não comporta diminuição nesta fase, ainda que confessados os fatos pelo réu.

Sem causa de aumento de pena. Por outro lado, ante a primariedade do acusado e da ausência de indicativos de que ele integre organização criminosa ou se dedique à atividade ilícitas, vislumbro o cabimento da redução de pena, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porém no menor patamar, a considerar a quantidade de droga apreendida, pelo que diminuo a pena em 1/3, considerando-se a primariedade e os bons antecedentes indicados, perfazendo o montante de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no menor valor.

Pois Bem.

Na sessão do dia 23.6.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos:

"O crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda. Por conseguinte, não são exigíveis requisitos mais severos para o livramento condicional (Lei 11.343/2006, art. 44, parágrafo único) e tampouco incide a vedação à progressão de regime (Lei 8.072/1990, art. 2º, § 2º) para os casos em que aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, Lei 11.343/2006. Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem de "habeas corpus" para afastar a natureza hedionda de tal delito. No caso, os pacientes foram condenados pela prática de tráfico privilegiado, e a sentença de 1º grau afastara a natureza hedionda do delito. Posteriormente, o STJ entendera caracterizada a hediondez, o que impediria a concessão dos referidos benefícios v. Informativos 791 e 828. O Tribunal superou a jurisprudência que se firmara no sentido da hediondez do tráfico privilegiado. Sublinhou que a previsão legal seria indispensável para qualificar um crime como hediondo ou equiparado. Assim, a partir da leitura dos preceitos legais pertinentes, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no art. 33, "caput" e § 1º, da Lei 11.343/2006 seriam equiparadas a crimes hediondos. Entendeu que, para alguns delitos e seus autores, ainda que se tratasse de tipos mais gravemente apenados, deveriam ser reservadas algumas alternativas aos critérios gerais de punição. A legislação alusiva ao tráfico de drogas, por exemplo, prevê a possibilidade de redução da pena, desde que o agente seja primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Essa previsão legal permitiria maior flexibilidade na gestão da política de drogas, pois autorizaria o juiz a avançar sobre a realidade pessoal de cada autor. Além disso, teria inegável importância do ponto de vista das decisões de política criminal." (Informativo nº 831, STF. HC 118.833/MS, rel Min. Cármen Lúcia, 23.06.2016) (g.n.).

No mesmo sentido, o STJ, em 23.11.2016, por meio de sua 3ª Seção, por unanimidade, acolheu a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, revisando o entendimento consolidado por ocasião do julgamento do REsp n. 1.329.088/RS - Tema 600, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO

ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria “contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa.” (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS – Tema 600). 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça (Petição nº 11.796 - DF (2016/0288056-2) RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 23.11.2016).

Diante disso, como decorrência lógica, e revendo entendimento anterior, não deverá, portanto, incidir no caso o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, na redação dada pela Lei 11.464/07, que estipula como regra o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Isso porque, de forma incidental, o Plenário do STF já declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, afirmando a possibilidade de o condenado por tráfico iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que o fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal (HC 111.840/ES, rel. Min.Dias Toffoli, j. 27.06.2012).

Por fim, é cabível, em tráficos privilegiados, A DEPENDER DO QUANTUM DA PENA E DOS DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CP, a substituição da sanção corporal por restritiva de direito. Ressalte-se que a Resolução 05/2012 do Senado Federal suspendeu a vedação de conversão em penas restritivas de direitos prevista no art. 44 da Lei de Drogas, declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS.

Em suma, não é possível hoje desconhecer que, notadamente a partir de decisões de seu Tribunal Pleno (HC 97.256/RS Rel. Ayres Britto j. 01.09.2010 m. v.; Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 663.261/SP Rel. Luiz Fux j. 13.12.2012 m. v.), tal lição tem sido torrencialmente ministrada em julgados unânimes de ambas as Turmas julgadoras do Supremo Tribunal Federal, a quem, inclusive, incumbe o controle máximo da constitucionalidade em nosso País (2ª T HC 124.489/MG Rel. Teori Zavascki j. 10.03.2015; 1ª T RHC 123.080/BA Rel. Luiz Fux j. 21.10.2014; 1ª T HC 111.015/MS Rel. Luiz Fux j. 21.05.2013; 2ª T HC 115.174/RS Rel. Gilmar Mendes j. 02.04.2013; 1ª T HC 123.622/SP Rel. Luiz Fux j. 23.09.2014; 1ª T HC 120.876/SP Rel. Luiz Fux j. 1ª T HC 120.663/SP Rel. Rosa Weber j. 29.04.2014; 2ª T RHC 120.247/MG Rel. Ricardo Lewandowski j. 25.02.2014; 1ª T HC 116.641/SP Rel. Marco Aurélio j. 25.02.2014; 2ª T HC 118.935/SP Rel. Ricardo Lewandowski j. 26.11.2013; 1ª T HC 115.508/SP Rel. Marco Aurélio j. 05.11.2013; 2ª T HC 115.350/MS Rel. Gilmar Mendes j. 29.10.2013; 2ª T HC 115.153/SP Rel. Gilmar Mendes j. 03.09.2013; 2ª T RHC 111.059/DF Rel. Ricardo Lewandowski j. 05.06.2012; 2ª T HC 111.247/MG Rel. Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012).

Não diverso tem sido também o entendimento unânime adotado pelas duas Turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça (5ª T HC 298.792/SP Rel. Newton Trisotto j. 24.03.2015; 6ª T HC 213.412/ES Rel. Nefi Cordeiro j. 19.03.2015; 6ª T HC 187.874/MG Rel. Nefi Cordeiro j. 19.03.2015; 5ª T HC 308.380/SP Rel. Leopoldo de Arruda Raposo j. 05.03.2015; 5ª T HC 299.780/SP Rel. Newton Trisotto j. 03.03.2015; 6ª T HC 309.663/SP Rel. Nefi Cordeiro j. 03.03.2015; 5ª T HC 291.136/SP Rel. Felix Fischer j. 24.02.2015; 5ª T HC 307.913/SP Rel. Felix Fischer j. 24.02.2015; 5ª T HC 306.352/SP Rel. Felix Fischer j. 12.02.2015; 6ª T HC 307.489/SP

Rel. Ericson Maranhão j. 12.02.2015; 5ª T HC 301.120/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 5ª T HC 292.602/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 5ª T HC 297.405/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 6ª T HC 310.798/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 03.02.2015; 6ª T AgRg no AREsp 436.420/DF Rel. Sebastião Reis Júnior j. 03.02.2015; 5ª T HC 304.439/SP Rel. Felix Fischer j. 03.02.2015). ASSIM, NO CASO EM ANÁLISE, ressalto que a pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial aberto, consoante art. 33º, § 2º, "c" do Código Penal (não reincidente e pena inferior a quatro anos).

Presentes os requisitos legais, substituindo somente a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no importe de 3 (três) salários-mínimos e meio a ser destinado ao Fundo Municipal da Infância e Juventude, nos termos do § 2º, segunda parte, do art. 44, do CP.

Assim, a pena perfaz o montante de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no menor valor, substituída a pena corporal por PRD, nos termos retro.

III – Do Dispositivo

Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LEONARDO DE JESUS SANTOS como incurso no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, devendo cumprir a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no menor valor, substituída a pena corporal por PRD, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no importe de 3 e 1/2 (três salários mínimos e meio) salário mínimo a ser destinado ao Fundo Municipal da Infância e Juventude, nos termos do § 2º, segunda parte, do art. 44, do CP.

A considerar a natureza da pena imposta, bem como a primariedade, CONCEDO-LHE o direito de recorrer em liberdade.

Custas na Forma da lei, visto que o réu é beneficiário da Lei nº. 1.060/50.

Deve a droga apreendida ser destruída se ainda não foi.

P.I.C.

Penápolis, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA